

1501904-93.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Felício Scaff

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/09/2022

... em sua segunda semana de atividade no tráfico por quitação da dívida. Diferentemente da versão apontada pelos policiais, negou ter dito que era gerente do tráfico de drogas e ter apontado o local onde estavam os demais entorpecentes. Alegou conhecer os outros dois indivíduos que conseguiram empreender fuga; se envolveu com as drogas desde muito cedo, quando ainda era menor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501904-93.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501904-93.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABRICIO DONIZETI LEITE DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Ricardo Felício Scaff

Vistos.

FABRICIO DONIZETI LEITE DA SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 17 h 30, na Rua Senador Robert Kennedy, nº 120, Jardim Fernão Dias, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu teria adquirido e guardado, 816 (oitocentos e dezesesseis) porções de "maconha" e 1923 (um mil, novecentos e vinte e três) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a terceiro, além da quantia de R\$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais), conforme o auto de exibição e apreensão - fl.11; laudo de constatação provisório - fls.18/23; fotografia - fl.24. Conforme a denúncia (fls.56/58) e, segundo o apurado, o réu, hipoteticamente, resolveu realizar comércio ilícito de drogas e, para isso, guardava grande quantidade de entorpecentes, em um imóvel, para que fossem comercializados para as pessoas que por ali passavam. Na ocasião, Policiais Militares, em tese, realizavam patrulhamento de rotina e avistaram FABRICIO com uma sacola nas mãos, em atitude suspeita, num local conhecido como "ponto" de venda de drogas, teriam notado ainda, que o réu esboçara nervosismo ao perceber a aproximação policial. A partir da abordagem, teoricamente, os Policiais Militares, encontraram na posse de FABRICIO,

uma sacola contendo em seu interior as drogas e a quantia mencionada acima. Assevera, a denúncia, que o acusado indicou o local onde estavam escondidas as demais drogas, e, franqueado o ingresso no imóvel, teriam sido encontradas três sacolas em um dos cômodos, com grande quantidade de entorpecentes, portanto, foi flagrado com substâncias ilícitas, especialmente embaladas, de diferentes qualidades e diversas quantidades, divididas de forma a permitir a imediata comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas. O réu foi preso em flagrante às fls.01.

Termo de Audiência de Custódia (fls.43/46), oportunidade em que foi concedida liberdade provisória, considerando que o crime em questão não é concretamente grave, especialmente em razão da pouco relevante participação do custodiado, que apenas guardava a droga; e que não há indícios de que o autuado integre organização criminosa, tampouco se dedique a atividades ilícitas, com base no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal. Alvarás fls.47/48. Regularmente notificado (fls.68), o réu, por intermédio de advogado dativo, apresentou defesa prévia (fls.69/71), pugnando pela absolvição ante às circunstâncias que lhe são favoráveis, reservando-se ao direito de apresentar demais alegações do mérito, apenas na fase dos memoriais finais.

Decisão em que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (fls.72/73).

Em audiência de instrução e julgamento (fls.100/101), foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, interrogado o réu.

Em alegações finais (fls. 104/117), o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, em primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ante a variedade e grande quantidade de drogas encontradas, quais sejam, mais de três quilos de maconha e mais de um quilo de cocaína; na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa; na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou diminuição, em especial o privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, já que, a despeito de sua primariedade, a elevada quantidade e variedade de drogas, aliada às condenações do réu por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas quando adolescente (cf. fls.27/30). No que tange ao regime, requereu o inicial fechado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena.

A d. defesa, por sua vez, em alegações finais (fls.119/131), pugnou pela improcedência da ação penal nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente absolvido por falta de provas capazes de ensejarem um decreto condenatório, além da coação moral irresistível. Requereu a desclassificação da conduta do réu para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Observou, quanto à dosimetria da pena, que na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal; na segunda fase, indicou que está presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa; na terceira fase, destacou que em caso de não haver desclassificação, seja aplicado o artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo. No que toca ao regime, requereu o inicial aberto e, o benefício do réu recorrer em liberdade.

Certidão de Antecedentes Criminais (fls.27/28) e Folha de Antecedentes (fls.74/75 e fls. 83/85).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do

mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), Termo de Depoimento (fls.03/04), Interrogatório (fl.05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl.11), Nota de Culpa (fs.12), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (tetrahidrocannabinol "THC" - massa líquida: 3104g e cocaína - massa líquida: 1202,64g - fls.18/23), Fotografia (fl.24), Laudo de Lesão Corporal Cautelar (fls.25/26), Depósito Judicial (fl.51), Relatório Final (fls.52/53), Laudo de Constatação e Descrição de Objetos (fls.91/99), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material "droga", indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06 - LD).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastasse, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, e explanou que, estava com dívidas acumuladas com traficantes; é usuário; estava sendo ameaçado juntamente com sua família, pois não havia feito o pagamento de algumas drogas que pegou; lhe disseram que iriam sequestrar sua filha, e ficar com ela até que sua dívida fosse quitada; caso não fosse vender a droga; não iria ter lucro, pois trabalharia para pagar sua dívida; sendo que cada semana pagaria R\$ 1.000,00 (um mil reais); devia aproximadamente R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); no dia dos fatos estava em sua segunda semana de atividade no tráfico por quitação da dívida. Diferentemente da versão apontada pelos policiais, negou ter dito que era gerente do tráfico de drogas e ter apontado o local onde estavam os demais entorpecentes. Alegou conhecer os outros dois indivíduos que conseguiram empreender fuga; se envolveu com as drogas desde muito cedo, quando ainda era menor de idade; está arrependido de se envolver com as drogas, e tem se dedicado a um processo de afastamento dos vícios de álcool e outros entorpecentes para proteger a sua família.

A par disso, a testemunha Rogério de Jesus Lacerda, Policial Militar, em juízo, narrou que, estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram três indivíduos em atividade suspeita; os suspeitos empreenderam fuga; resolveram seguir e abordar FABRÍCIO, pois estava com uma sacola na mão, na qual, posteriormente, verificaram presença de cocaína e maconha; na abordagem o réu disse que era gerente do ponto de venda de drogas e que havia quantidade maior em outro local; ocasião em que, com autorização do acusado, entraram num cômodo vazio e encontraram numa mochila apontada por FABRÍCIO uma porção maior de drogas e uma quantia em dinheiro.

Igualmente, a testemunha Wellington de Oliveira Marques, Policial Militar, declarou que, o local é conhecido como ponto de tráfico; no dia dos fatos, em patrulhamento, visualizaram três indivíduos que empreenderam fuga e decidiram abordar FABRÍCIO, pois estava com uma sacola. Em abordagem, verificaram que na sacola havia uma pequena porção de drogas fracionadas; o réu confessou que estava em atividade de tráfico de drogas, na função de gerente, e ainda, apontou um imóvel que tinha alugado afirmando que lá estava uma quantidade maior de drogas. No imóvel vazio, havia apenas uma mochila com uma quantidade maior de drogas e algum dinheiro. Ressalta-se que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator Min: CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que o réu praticou os núcleos "adquirir", "guardar" e "vender", previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal. Outrossim, extrai-se o seu intuito comercial do próprio local em que concretizada a abordagem, qual seja, ponto de mercancia de drogas.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, ainda nesta hipótese, restaria consumado o crime.

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal e ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, observo que diante da natureza distinta entre os entorpecentes e potencial lesivo, a pena deve ser exasperada em 1/8. Destarte, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

De outro lado, incide a atenuante da confissão, utilizada para a formação do convencimento deste magistrado, imperiosa a incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e ainda, a atenuante da maioridade relativa, disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, reduzo a pena para o patamar de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição. Não é possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, pois ausentes os requisitos, em especial a conduta social, circunstâncias do art. 59 do CP, tendo em vista que o modo como cometido o crime, isto é, grande quantidade e diversidade de drogas, conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que consistem na prática do crime em local conhecido como "ponto de tráfico" em concurso com outros agentes, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Assim, torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o semiaberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada, inviável a substituição ou suspensão condicional da pena.

Ante o exposto e considerando que tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal pública incondicionada para condenar o réu FABRICIO DONIZETI LEITE DA SILVA, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput", e parágrafos, do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante o processo.

Ainda, atendendo a nova redação do artigo 387, § 2º, Código Processual Penal, dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe este magistrado de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo juízo da execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitativa - fruto da mercancia da droga-, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Mairiporã, 04 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA